

1500346-48.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... apenso), ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500346-48.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-48.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047603/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 23111209 - 02º D.P. AMERICANA, 322/22/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2047603 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ANDERSON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada, tentou subtrair, para si, 03 luminárias, avaliadas no total de R\$210,00, pertencentes a um estabelecimento, cujo representante é O.S.R., não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2012 (fls. 97/99).

O réu foi citado (fls. 144), apresentando defesa prévia (fls. 130/131).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 146/147).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 183/187), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado tentado.

A Doutora Defensora (fls. 190/192) requereu a aplicação da atenuante da confissão, com fixação de pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01/02, 07/09, 10/16 e 161, e laudo de fls. 174/179.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEa, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEa, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva,

1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - (...) - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A testemunha Osmar informou que trabalha para o proprietário do imóvel, Ademar, sendo que este não estava disponível no dia dos fatos, razão pela qual dirigiu-se ao imóvel. Disse, ainda, que no local já se encontrava a polícia, e visualizou um indivíduo no interior do imóvel, sendo que os policiais pediram para que ele saísse. Narrou, também, que o réu pulou o muro, de cerca de três metros, e os policiais acabaram por deter o indivíduo. No interior do imóvel, viu as luminárias que foram retiradas.

Não há nos autos prova de que a testemunha conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime. No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

O Policial Militar, ouvido em Juízo, esclareceu que foram informados de um possível furto em andamento, sendo que um indivíduo havia escalado o muro, dirigindo-se até o local. Declarou, ainda, que quando chegaram, visualizaram o réu na parte superior do galpão, andando de um lado para o outro, sendo que ignorou a ordem para sair do imóvel. Narrou que com a chegada do representante, foi possibilitada a entrada, e viram o réu com uma mochila nas costas, próximo de uma mesa com três luminárias, sendo que este tentou evadir-se, pulando um muro. Em abordagem, localizaram dentro da mochila uma chave turquesa.

O réu Anderson, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto, declarando que tinha consumido álcool e drogas, e pulou o muro. Disse, ainda, que tinham intenção de subtrair as luminárias, que estavam no chão, para trocar por drogas.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed.,

2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca da qualificadora (escalada), reforçada pelas testemunhas e pelo próprio réu, não sendo possível a desclassificação para o delito de furto simples.

Ainda, a qualificadora de escalada encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 174/179, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

No mais, não há que se falar em crime de bagatela ou insignificância, figura desconhecida no nosso ordenamento jurídico.

O pequeno valor da coisa não serve para legitimar o comportamento em questão, mas apenas para eventual abrandamento de pena em caso de furto privilegiado, o que não ocorreu no presente caso.

Na doutrina de Júlio Fabrini Mirabete:

"A excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, não está inserida na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 3/345) .

(...) Segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial. (Manual de Direito Penal, 21a. Ed. vol. I, p. 118/119)

E o próprio Mirabete exemplifica:

"É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito,

uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja o efetivo desfalque do patrimônio alheio". (Idem, vol.II, pág.225/226).

O Desembargador Souza Nery, de forma assaz pertinente, assim coloca a questão: "Quanto à tese do crime de bagatela, entendo que não se aplica ao caso o chamado princípio da insignificância. O ordenamento jurídico brasileiro não contemplou – malgrado o desejo de muitos – o princípio da bagatela, a cujo respeito já se disse decorrer de verdadeira insignificância de princípios." (TJSP – AC - 990.09.058638-9, 9ª Câmara Criminal, j. 27.08.09).

Da mesma forma, o Desembargador Xavier de Aquino entende que a pequena quantia subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada não tornam atípica a conduta, embora possam, desde que presentes outros requisitos, permitir o reconhecimento do furto privilegiado. De acordo com o eminente Magistrado:

"Pensar de forma diferente seria transformar as ruas em palco de treinamento para delinquentes. Se apanhados permanecem impunes diante da aplicação do princípio da insignificância. Por outro lado, se a conduta é bem sucedida também saem ilesos". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 990.09.218713-9, Americana, 11ª Câmara Criminal, j. 09.12.2009).

Em julgado da apelação nº 0001914-88.2012.8.26.0581, da Comarca de São Manoel-SP, assim decidiram nossos tribunais.

"Tocante à aplicação do princípio da insignificância, deve-se ter em mente que o fato não pode ser considerado atípico somente em decorrência do valor da coisa furtada, ou porque os bens foram recuperados. Para tanto, creio ser indispensável a presença de outros requisitos estabelecidos pela doutrina e pela Jurisprudência: 1) ofensividade mínima; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade; 4) inexpressividade da lesão jurídica causada (STF, HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/11/04; HC 96.202;/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/05/10; STJ, REsp 1133800, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/06/10; HC 164.993/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14/06/10; HC 152.738/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJe de 15/03/10). O réu é reincidente (certidões de fls. 11/12 do autuado em apenso), ostentando condenações pela prática de tráfico de drogas e furto. A nova investida contra o patrimônio alheio, portanto, denota que sua conduta é dotada de ofensividade e reprovabilidade, na medida em que deixa entrever a presença de destemor, de uma quase certeza da impunidade, fazendo emergir a expressividade da lesão, a encomendar a intervenção do Direito Penal. Nesse sentido: STF "O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal", HC 102.088, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/05/10.

Não se pode confundir baixo grau de lesividade com sua absoluta inexistência, pena de adotar-se, como regra, a impunidade em casos como os em comento. Daí porque se justifica a "persecutio criminis in iudicio".

Nos dias atuais, em que a sociedade presencia o recrudescimento de toda espécie de criminalidade, em que as instituições responsáveis pela aplicação da lei e pela manutenção da segurança e ordem pública sofrem com o descrédito da população, em que a sensação de insegurança está pulverizada em todo o corpo social, o princípio da insignificância deve ser aplicado com redobrada cautela, devendo constituir exceção e não regra, pois do contrário o Judiciário estará alimentando esse sentimento de desassossego, fomentando o crime e a impunidade.

Pelo que tenho notado a jurisprudência não se pacificou com relação à incidência do princípio. Pelo contrário, atualmente tem passado a analisar o crime sob o enfoque da vítima, sob o prisma de quem está perdendo – e para quem, via de regra, a

conduta é dotada de lesividade. Nesse sentido pronunciou-se o Min. Luiz Fux no julgamento do HC nº 100.690 (Supremo Tribunal Federal): "Eu tenho muita preocupação com essa teoria, porque as jurisprudências dos tribunais têm um caráter exemplificativo para a sociedade. Então, se nós chegamos aqui para dizer que furtar dois DVD's não é crime, nós estamos exatamente tornando antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita". (AC 2014.0000633914, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Orlando, 06.10.2014).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PENAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DA RES PALAVRAS DE TESTEMUNHAS RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL - PENA E REGIME REESTRUTURADOS - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDO-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da insignificância, porquanto constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurídicos. - Estando comprovada a autoria do delito pela confissão do agente, apreensão da res furtiva em seu poder e depoimento de testemunhas, a condenação é medida que se impõe. Sendo a apelante primária e a res furtiva de pequeno valor é de se reconhecer o furto privilegiado na espécie nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação nº 990.09.366733-9 - 12ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi - j. 19.05.2010)

FURTO - Bem subtraído que possui valor econômico, ainda que pequeno - Reconhecimento de crime de bagatela - Impossibilidade: 52(a) - Quando o bem subtraído possui valor econômico, ainda que pequeno, é impossível o reconhecimento do crime de bagatela, não se caracterizando o delito do art. 155 do CP apenas quando não se puder avaliar o produto do furto diante da insignificância da lesão jurídica, como na subtração de um ovo, de ramas de mandioca, de folhas de palmeira etc. (Apelação nº 1.101.025/3, Julgado em 14/09/1.998, 12ª Câmara, Relator: José Habice, RJTACRIM 41/170).

No mais, a existência da prática reiterada de crimes, comprovado nos presentes autos com a reincidência e/ou maus antecedentes, impossibilita a análise do referido benefício.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.194/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BEM DE VALOR CONSIDERÁVEL. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A conduta narrada nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, pois o valor do bem subtraído não se revela ínfimo, correspondendo a cerca de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo vigente à

época dos fatos, sendo certo que o furto em questão não representa fato isolado na vida do paciente, que já foi condenado por crime semelhante, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir a reiteração criminosa. 3. (...). (HC n. 330.156/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 10/11/2015.)

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimizabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPONIBILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPONIBILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimizabilidade ou em semi-imponibilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imponibilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimizabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimizabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, o de ter sido surpreendido pelos policiais.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 59/60) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto qualificado (escalda), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base na 1/5 (um quinto), delimitando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 59/60. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena da 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido, perfazendo assim um total de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal em caso de furto qualificado. Além disso, para que o benefício fosse

concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. 2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

FURTO QUALIFICADO - Aplicação do privilégio - Impossibilidade:117 - É impossível a aplicação do privilégio ao furto qualificado, vez que o agente de tal delito representa maior soma de perigo para a sociedade, tanto que o Legislador Penal teve o cuidado de tratar do benefício antes das circunstâncias qualificadoras. RJDTCRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 220 RELATOR: - THYRSO SILVA

Ademais, os péssimos antecedentes do réu desaconselha a adoção de tal benefício.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu ANDERSON DA SILVA à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.
P. I. C.

Americana, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA